DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 20-2024-ACVDLC-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio LUCS

Demandado : Municipalidad Distrital de el Carmen de la Frontera - Piura.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Ana Cristina Velásquez de la Cruz.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

FECHA DE INICIO : 26 de noviembre de 2024.

FECHA DE CONCLUSION : 07 de enero de 2025.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Trujillo, 26 de noviembre de 2024.

RESOLUCIÓN DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA N°01

VISTOS:

(i) El escrito sumillado como "***Solicito se dicte medida cautelar"*** presentado por Consorcio Lucs.

CONSIDERANDO:

A.- GENERALIDADES SOBRE EL ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

1. El arbitraje de emergencia es una forma de tutela cautelar que, el ordenamiento jurídico otorga a las partes de un arbitraje con la finalidad que la decisión emitida en este sea válida y, sobre todo, eficaz, de conformidad al respeto de la tutela jurisdiccional efectiva.

2. En los términos que explica el profesor Giovanni Priori Posada[1], la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra íntimamente ligada a la eficacia de la decisión, respecto de ello escribe las siguientes líneas:

> *El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho, cuyos efectos deben poder producirse en el ámbito de la realidad (45).*
> *Es importante subrayar el hecho de que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no solo garantiza el derecho que tienen los ciudadanos acceder a la justicia, ni se queda en que el proceso sea llevado respetando garantías mínimas, sino que, en aras de hacer real y eficaz la protección que desea dar, garantiza también que el proceso alcance el fin para el que fue iniciado.*

3. Bajo ese sentido, el numeral 1 del artículo 63° del Reglamento de Arbitraje del Centro, señala que es derecho de las partes solicitar medidas cautelares urgentes de forma previa a iniciar el arbitraje propiamente dicho.

> Artículo 63°.-
> Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
>
> 1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud

4. A través del numeral 11 del escrito de vistos (i), el demandante ha solicitado al Árbitro de Emergencia al trámite de la misma sin conocimiento de la Entidad, alegando que esta podría adoptar acciones que puedan frustrar la eficacia de la medida, según se lee del citado escrito:

[1] Priori Posada, Giovanni (2005). *El derecho fundamental a la tutela cautelar: fundamentos, contenido y límites*. Ius Et Veritas, (30) p. 179.

el monto que nos indique el arbitro de emergencia.

11. **TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR SIN CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD**

11.1. En nuestro ordenamiento jurídico las medidas cautelares se tramitan y se resuelvan *inaudita altera parte,* es decir, sin oír al sujeto pasivo de la medida cautelar. Esto por una razón muy sencilla: si el sujeto pasivo toma conocimiento de la intención de la parte activa de obtener una medida cautelar, podrá adoptar todas aquellas acciones a efectos de frustrar la eficacia de dicha medida.

5. De conformidad con el primer párrafo del artículo 64° del Reglamento, se advierte que el trámite de medidas cautelares se realiza, por regla general, en conocimiento de la contraparte, según se puede leer:

> ***Artículo 64º.- Trámite de la medida cautelar***
> *Antes de resolver, el Tribunal Arbitral pondrá en conocimiento de la contraria la solicitud cautelar; no obstante, ello, podrán dictar una medida cautelar sin conocimiento de la contraria cuando quien solicite justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. El Tribunal Arbitral podrá exigir contracautela. Ejecutada la medida cautelar, cabe interponer recurso de reconsideración.*

6. Por tanto, en atención a la decisión del Árbitro de Emergencia designado para el análisis de la presente causa, así como a efectos de garantizar el derecho de defensa de la Entidad, se procede a poner en su conocimiento el pedido de medida cautelar ante árbitro de emergencia contenido en el escrito de visto (i), para efectos que pueda manifestar lo que estime pertinente a su derecho.

7. Se deja constancia que, posteriormente al plazo concedido por el Árbitro de Emergencia, con o sin la absolución de la Entidad, se citará a ambas partes a la realización de una audiencia especial para discutir la medida cautelar, según se considere pertinente.

B.- SOBRE EL PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTO POR CONSORCIO LUCS

8. Que, mediante escrito de vistos (i) el Consorcio Lucs solicitó al Centro de Arbitraje que el Árbitro de Emergencia emita una medida cautelar sobre el particular, según se puede leer:

> Sebastián Melendres Ubillos.
>
> 3. **PRETENSIÓN CAUTELAR:**
>
> En amparo de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento Arbitraje del Centro de Arbitraje – CECARD y el artículo 47 del Decreto Legislativo Nro. 1071 Ley de Arbitraje; SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN:
>
> - ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, SE ABSTENGA A EJECUTAR la garantía de Fiel Cumplimiento, otorgado por nuestra representada mediante CARTA FIANZA Nº 1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles).

9. Debe tomarse en consideración que el petitorio cautelar formulado por el contratista versa respecto de una medida de no innovar sobre la ejecución de la Carta Fianza N°1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE, constituida como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

10. No obstante, a consideración del Árbitro de Emergencia, ante la evaluación de la Solicitud de Medida de Emergencia, es decir, de su contenido y, principalmente, de su petitorio, en aras de garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios que puede ocasionar la ejecución de la medida, estima por pertinente dictar una medida provisional. Por lo tanto, en los siguientes considerandos se consignará a detalle en qué consiste el dictado de una medida de este calibre y la facultad que tiene el Árbitro de Emergencia para concederlas.

B.1.- Facultad del Árbitro de Emergencia para dictar medidas provisionales.

- Ahora bien, en buena cuenta, las medidas provisionales son resoluciones adoptadas por los árbitros para mantener la situación existente durante el procedimiento, hasta que se dicte una resolución definitiva poniendo fin al litigio.

- La doctrina ha dejado en claro que la Ley de Arbitraje peruana, cuando refiere a medidas cautelares engloba a todo tipo de medidas[2], ello en razón a que las disposiciones referidas a medidas cautelares encuentran su razón de ser en garantizar la tutela efectiva, la cual, según el Tribunal Constitucional[3] "*supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia*".

- Asimismo, el Código Procesal Civil peruano, norma de referencia en materia procesal en el derecho peruano, indica en su artículo 618°, lo siguiente:

> ***Art. 618.- Medida anticipada***
> *Además de las medidas cautelares reguladas el Juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva.*

- Por lo tanto, la función jurisdiccional implica que el árbitro, en ejercicio de esta, brinde a las partes todas las garantías correspondientes al debido proceso a efectos de asegurar la tutela jurisdiccional efectiva, según ha dejado entrever el Tribunal Constitucional en la STC N°02851-2020-PA/TC y STC N°00142-2011-PA/TC.

- En consecuencia, se concluye que es parte de la potestad jurisdiccional del árbitro la dación de medidas provisionales bajo los criterios contemplados en la ley de arbitraje como parte de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva que atiende al presente proceso.

---

[2] Amprimo Plá, Natale. (2013). La tutela cautelar arbitral. *Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho*, (44), pp. 59-79.

[3] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N°8123-2005-PHC/TC: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/08123-2005-HC.pdf.

B.2.- Naturaleza jurídica del pedido cautelar de Consorcio Lucs

- Que, es menester recordar que, según lo advertido en el expediente de arbitraje de emergencia, la solicitada es de naturaleza no innovativa, con la finalidad de lo siguiente:

  - Ordenar a la Entidad a que se abstenga de realizar actos que signifiquen ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato emitida a favor de la Entidad.

- Empero, tomando en consideración que, en materia de contrataciones del Estado las garantías son de ejecución automática, de conformidad con el numeral 2 del artículo 33° de la Ley de Contrataciones del Estado:

> **Artículo 33. Garantías**
>
> 33.1 Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.
> 33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

- En consecuencia, se advierte que la medida cautelar solicitada implica la ejecución de garantías que, se derivan de una resolución contractual que, a la fecha no quedaría consentida la resolución del contrato o sin la existencia de laudo arbitral firma sobre el particular, de conformidad con el literal b), del numeral 1, del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según se lee:

> *b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado*

- Por lo tanto, el contratista ha anexado a su solicitud la Carta Notarial N°006-2024-MDCF/ALC, recibida por la empresa aseguradora el 25 de noviembre de 2024, según se puede apreciar:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL RURAL Y FRONTERIZA
EL CARMEN DE LA FRONTERA – HUANCABAMBA
(Creado Por Ley 15248 Del 30 De Noviembre De 1964)

NOTARÍA CÁRDENAS
Av. Saénz Peña N° 2311 José L. Ortiz
Telef.: (074) 257319 - Telefax: 257320
22 NOV. 2024
RECIBIDO
HORA: FIRMA:

NOTARÍA CÁRDENAS
JAIME CÁRDENAS FONSECA
NOTARIO - ABOGADO
CARTA NOTARIAL N°: 1745
FECHA: 22-11-2024

CARTA NOTARIAL N° 006-2024-MDCF/ALC

FOGAPI
OFICINA ESPECIAL PERMANENTE
CHICLAYO
25 NOV. 2024
RECIBIDO
Hora: 10:48 am

Huancabamba, 12 de noviembre de 2024.

SEÑOR:
OSCAR PORTOCARRERO QUEVEDO
Gerente General
FOGAPI
Calle Manuel María Izaga N° 369
Chiclayo

Presente.-

JAIME CÁRDENAS FONSECA
NOTARIO - ABOGADO

ASUNTO: EJECUCION DE CARTA FIANZA
REFERENCIA: N° 1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de solicitarle la ejecución de la Carta Fianza de la referencia a favor de nuestra entidad, en merito a la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo al siguiente detalle:

N°	CARTA FIANZA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO S/.
01	N° 1118007-2020/FG/OEP/LAMBAYEQUE	18/11/2020	13/11/2021	S/. 1'716,326.82
02	N° 1108016-2021/FG/OEP/LAMBAYEQUE	08/11/2021	12/005/2022	S/. 1'716,326.82
03	N° 0510003-2022/FG/OEP/LAMBAYEQUE	10/05/2022	08/11/2022	S/. 1'716,326.82

- Por lo que, se advierte que existe una necesidad de dictar una medida provisional hasta que se pueda discutir el pedido cautelar formulado por Consorcio Lucs, siempre que existe un inminente riesgo que la medida cautelar quede sin efecto ante la ejecución de dicha garantía.

- Ahora bien, **¿qué ocurriría si no se concede la medida provisional en el presente caso?** El Árbitro de Emergencia considera que, de no dictarse la medida, se vulneraría el derecho del solicitante de la Medida de Emergencia a la tutela jurisdiccional efectiva, debido a que no se estaría garantizando el resarcimiento de los daños y perjuicios que podrían ocasionar la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento otorgada en favor de la Municipalidad Distrital El Carmen de la Frontera.

- Asimismo, se deja constancia de que el Consorcio requiere, por la situación jurídica en que se encuentra inmersa a causa de los conflictos que se encuentra atravesando debido a las controversias derivadas del Contrato N°22-2020-MDCF, que su petitorio cautelar se vea salvaguardado para que no exista una posible descompensación o afectación a su persona en caso la Entidad opte por ejecutar la carta fianza a causa de la resolución contractual que ellos habrían realizado.

- Sin embargo, antes de que se realice la Audiencia Especial de Medida Cautelar, en la cual se discutirá si se otorgará o no la medida cautelar

solicitada, opta por pertinente el otorgamiento de una medida provisional que garantice, desde que el solicitante activa el fuero arbitral, la posible concesión de una medida cautelar, atendiendo a que el dictado de la misma se vea protegido con una medida anterior a esta, esto es, con la medida provisional.

- Así las cosas, es más que evidente la necesidad de dictar una medida provisional antes de la medida cautelar, puesto que, en aras al numeral 1 del artículo 47° de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071), esta facultad está concedida al Árbitro para que se impida un daño o el menoscabo del proceso arbitral, dado cuenta la naturaleza de la controversia.

11. En ese sentido, mediante el presente acto procesal se dispone correr traslado del pedido de variación de la medida cautelar de emergencia a la Municipalidad Distrital El Carmen de la Frontera, por un plazo de dos (02) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente, para que manifieste lo correspondiente a su derecho, dictando la medida provisional materia de análisis en la presente Resolución.

Por las consideraciones expuestas, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:**

PRIMERO: TENER POR PRESENTADO el escrito de vistos (i) sumillado como “Solicito se dice medida cautelar” presentado por el **CONSORCIO LUCS**.

SEGUNDO: En consecuencia**, CORRER TRASLADO** del citado escrito de vistos (i) referido al pedido de medida cautelar, a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL CARMEN DE LA FRONTERA** para que, en el **PLAZO DE DOS (02) DÍAS HÁBILES**, computados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente, cumpla con manifestar lo que considere pertinente a su derecho.

TERCERO: DISPONER a manera de **MEDIDA PROVISIONAL** que la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL CARMEN DE LA FRONTERA** cumpla con **SUSPENDER** el procedimiento de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento constituida con la Carta Fianza N°1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitida por **FOGAPI**, a favor de la Municipalidad Distrital El Carmen de la Frontera, respecto del Contrato N°22-2020-MDCF.

CUARTO: COMUNICAR la presente medida provisional a la empresa **FOGAPI**, a efectos que tome conocimiento del particular y **SUSPENDA** el procedimiento de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento constituida con la Carta Fianza N°1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitida por FOGAPI, a favor de la Municipalidad Distrital El Carmen de la Frontera, respecto del Contrato N°22-2020-MDCF.

QUINTO: PRECISAR que, posteriormente al plazo concedido por el Árbitro de Emergencia, con o sin la absolución de la Entidad, se citará a ambas partes a la realización de una audiencia especial para discutir la medida cautelar, según se considere pertinente.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes involucradas en este procedimiento arbitral según corresponda.

La presente Resolución se emite con la revisión y aprobación del **ÁRBITRO DE EMERGENCIA**: CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS. –

CARLOS ENRIQUE ALVAREZ SOLIS
ÁRBITRO DE EMERGENCIA

Resolución N° 03
Lima, 12 de diciembre de 2024

VISTOS:

- **i)** Resolución de Arbitraje de Emergencia N° 01 del 26 de noviembre de 2024.
- **ii)** Resolución N° 02 de fecha 03 de diciembre de 2024.
- **iii)** Acta de Audiencia Especial de fecha 05 de diciembre de 2024.
- **iv)** Carta N° 439-2024-MPH-PPM de fecha 06 de diciembre de 2024 presentado por la Procuraduría Pública Municipal de Huancabamba – Alegatos Medida Cautelar.
- **v)** Razón de Secretaría Arbitral de fecha 11 de diciembre de 2024
- **vi)** Razón de Secretaría Arbitral de fecha 05 de diciembre de 2024

CONSIDERANDO:

1. Mediante la Resolución de vistos **ii)**, debidamente notificada a las partes el 03 de diciembre de 2024, según los cargos que obran en el expediente, se dispuso lo siguiente:

> *"Por lo que, estando a lo expuesto, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:***
> ***Primero: DECLARAR** válidamente constituido al Árbitro de Emergencia del presente caso, Abogada Ana Cristina Velásquez De La Cruz, en reemplazo del Abogado Alvarez Solis.*
> ***Segundo: CITAR** a las partes a una Audiencia Especial virtual para el **jueves 05 de diciembre de 2024 a las 10:00am,** a efectos de que presenten y/o sustenten sus posiciones. La secretaría remitirá el link v de la audiencia un día antes de su realización.*
> ***Tercero: TRASLADAR** a ambas partes los documentos de vistos i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x), y xi) para conocimiento y fines pertinentes.*
> ***Cuarto: DISPONER** que la secretaria Arbitral notifique las partes la presente resolución."*

2. Mediante el Acta de vistos **iii),** se dejó constancia del desarrollo de la Audiencia Especial llevada a cabo el 05 de diciembre de 2024 a las 10:00 am, con la participación de ambas partes, en el que tuvieron la oportunidad de manifestar, en igualdad de condiciones, sus posiciones y ejercer su derecho de expresión. Por otro lado, durante la audiencia, la Árbitro Único formuló las preguntas que consideró pertinentes y, por acuerdo de las partes, concedió el plazo de un (01) día hábil, contado a partir de la notificación de dicha acta, para que las partes puedan presentar sus alegatos finales.

3. En ese sentido, dentro del plazo otorgado, la Procuraduría Publica de Huancabamba presentó la Carta de vistos **iv),** a través del cual presentó sus alegatos, lo cual se tiene por cumplido y presente al momento de resolver.

4. Mediante la Razón de Secretaría de vistos **v),** la secretaria arbitral informó, entre otros, lo siguiente:

"2. Con fecha, 24 de setiembre del año en curso, el Consorcio LUCS presento solicitud de arbitraje ante nuestra institución, sin embargo, hasta la fecha no han solicitado la designación de arbitro, estando suspendido el trámite de dicha solicitud.

3. Por otro lado, se le informa que habiéndose realizado la audiencia especial en el presente proceso el 05.12.2024, se concedió a las partes el plazo de un (01) día hábil a efectos de que puedan presentar sus resúmenes finales. Dicho plazo venció el 10.12.2024[1] habiendo únicamente la Procuraduría Publica de Huancabamba presentado su escrito."

5. En razón a lo indicado, corresponde dejar constancia que CONSORCIO LUCS no presentó alegatos dentro del plazo otorgado en el Acta de vistos **iii).**

6. Teniendo en cuenta el estado del presente arbitraje de emergencia, la Árbitro de Emergencia, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad con el artículo 3 del Anexo I del Reglamento de Arbitraje del Centro, procederá a continuar con las actuaciones arbitrales que obran en el presente proceso, absolviendo previamente, los incidentes presentados antes de su designación.

Respecto a la competencia de la Árbitro, Abogada Ana Cristina Velásquez De La Cruz

7. Mediante Resolución de vistos **i),** el Abogado Álvarez Solís dispuso, entre otros, lo siguiente: i) Tener por presentado la solicitud de medida cautelar presentada por el Consorcio, ii) Correr traslado a la Entidad, a fin de que manifieste lo conveniente a su derecho, iii) Disponer a manera de medida provisional que la Municipalidad cumpla con suspender el procedimiento de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento constituida con la Carta Fianza N° 1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitida por FOGAPI, iv) Comunicar a FOGAPI la medida provisional a efectos que tome conocimiento de la referida resolución y suspenda el procedimiento de ejecución la garantía de fiel cumplimiento.

8. Al respecto, mediante la Carta de vistos **iii),** la Procuraduría Publica de Huancabamba refirió que la medida cautelar concedida por el anterior árbitro de emergencia Abogado Álvarez Solís, se ha realizado sin respetar el procedimiento prescrito de manera imperativa en la Ley N° 31589 - Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas; motivo por el cual, solicita la nulidad de dicha resolución.

9. Sobre el particular, corresponde precisar que las prerrogativas del árbitro de emergencia tienen como parámetros los límites que la norma adjetiva y sustantiva imponen en cuanto al otorgamiento de la tutela cautelar, lo cual supone que para el otorgamiento de una medida cautelar, no se puede desconocer ciertos presupuestos y requisitos exigidos por mandato legal.

10. Dado que la competencia del Árbitro de Emergencia ha sido cuestionada por la Entidad, se emitirá un pronunciamiento sobre este particular:

[1] Se deja constancia que los días viernes 06.12.2024 fue declarado feriado para el sector público y recuperable para el privado, así como el 09.12.2024 es un feriado nacional.

- La Procuraduría Publica de Huancabamba, a través de la Carta de vistos **iii),** refirió que conforme al artículo 1 de la tercera disposición complementaria final de la Ley N° 31589, la medida cautelar debió ser planteada ante un juzgado civil de la provincia de Huancabamba, o en su defecto, ante un centro de arbitraje del departamento de Piura.

- De manera preliminar, corresponde tener en cuenta que la cláusula vigésima primera del Contrato, que indica lo siguiente:

  *"**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS***

  Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

  Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

  Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

  El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado".

- Conforme se puede advertir, el convenio arbitral no encomienda la administración del arbitraje a una institución arbitral en particular ni tampoco limita o excluye la posibilidad de recurrir al arbitraje de emergencia[2]. Por el contrario, el marco general de compras públicas habilita a cualquiera de las partes a iniciar un arbitraje para resolver controversias ante cualquier institución arbitral[3], permitiendo la posibilidad de que dicho procedimiento incluya etapas previas, como lo es el arbitraje de emergencia, <u>siempre que este mecanismo esté previsto en el reglamento del centro arbitral que las partes eventualmente elijan.</u>

---

[2] El arbitraje de emergencia se configura como una medida destinada a proteger derechos urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral. Su aplicación no contraviene el contenido del convenio arbitral ni la normativa aplicable, en la medida en que no afecta la esencia del arbitraje como mecanismo de solución de controversias previsto por las partes.

[3] Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF
Articulo 225.- Arbitraje
(…)
225.4. De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, corresponde a la parte interesada recurrir a la institución arbitral elegida en aplicación del respectivo Reglamento arbitral institucional.

- En el presente caso, el CONSORCIO LUCS presentó su solicitud de arbitraje de emergencia ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, el cual contempla el arbitraje de emergencia en el Anexo I de su Reglamento de Arbitraje. Por tal motivo, el presente arbitraje de emergencia no desvirtúa las disposiciones establecidas en el convenio arbitral contenido en la cláusula vigésima primera del Contrato.

11. Por tal motivo, en virtud al principio *kompetenz – kompetenz,* se verifica que la suscrita tiene competencia para analizar las controversias del presente arbitraje de emergencia. Por tal motivo, corresponde avocarse al análisis de la legitimidad de quien presentó la solicitud cautelar.

Cuestionamiento respecto a las facultades de representación de quién presentó la solicitud cautelar

12. La defensa de la Entidad cuestionó que la solicitud cautelar presentada por el Consorcio fue realizada por el Sr. Luis Ccasani Salazar en calidad de representante común del Consorcio. Sin embargo, refiere que la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 244-MDC/ALC aprobó el cambio de representante común del Consorcio al Sr. Augusto Julio Tenorio Palomino.

13. Asimismo, la Entidad sostuvo durante el desarrollo de la Audiencia Especial que la empresa S&T Contratistas y Servicios Múltiples S.R.L., quién cuenta con una participación del 90% respecto de Consorcio Lucs, formalizó a través de la Adenda N° 01 al Contrato de Consorcio, la modificación del representante común, designando al señor Augusto Julio Tenorio Palomino el 08 de agosto de 2024. Agregó la Entidad que esta modificación unilateral del representante común se debió a que en diversas oportunidades se citó notarialmente al señor Luis Cassani Salazar para dejar sin efecto su designación como representante común.

14. La Entidad adjuntó, entre otros medios probatorios, (**i)** la Adenda N° 01 al Contrato de Consorcio Lucs de fecha 08 de agosto de 2024 y anexos (cartas notariales cursadas al señor Cassani citándolo a reunión para cambiar al representante común del Consorcio), **(ii)** la Resolución de Alcaldía N° 0244-2024-MDCF/ALC de fecha 11 de setiembre de 2024, **(iii)** Contrato de Consorcio de fecha 03 de noviembre de 2020.

15. Por otro lado, obra en el expediente arbitral de emergencia también el Acta de Conciliación N° 321-2024 del 29 de agosto de 2024, suscrita por el representante de la Entidad y el representante común de Consorcio Lucs, Sr. Luis Cassani Salazar.

16. En razón a lo indicado, se puede advertir que la Entidad no reconoce al señor Luis Cassani Salazar la calidad de representante común del Consorcio, debido a que le fue comunicada la destitución de éste por la empresa S&T Contratistas y Servicios Múltiples S.R.L. Asimismo, sostiene que su postura se encuentra avalada por lo establecido en los artículos 61 y 63 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 y en lo dispuesto en la Opinión N° 094-2019/DTN del 10 de junio de 2019.

17. Por su parte, el señor Cassani sostuvo durante la Audiencia que mantiene la representación del Consorcio, dado no se ha suscrito ninguna modificación al Contrato de Consorcio de 03 de noviembre de 2020.

18. A efectos de emitir pronunciamiento respecto al incidente presentado respecto a quién ostenta la calidad de representante común del Consorcio, se debe tener en cuenta el orden de prelación normativa contemplado en el marco general de compras públicas, aplicable a las controversias que surjan durante la ejecución del Contrato sometido a competencia del Árbitro. Así, de acuerdo a la fecha de convocatoria del proceso de selección, se puede determinar que el marco general de compras públicas aplicable es el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 (en adelante, LCE) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, RLCE).

19. Al respecto, el numeral 10 del artículo 45 de la LCE, señala lo siguiente:

    "45. Medio de solución de controversias en la ejecución contractual
    (…)
    45.10. Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente norma y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público. (…)

20. En ese orden de ideas, debemos identificar si en el orden de prelación establecida en el marco general de compras públicas, existe alguna disposición que permita identificar con absoluta claridad en que casos y de que forma procede el cambio de representante común del Consorcio.

21. Así, se advierte que el artículo 140 de RLCE establece lo siguiente:

    "Artículo 140. Contrato de consorcio

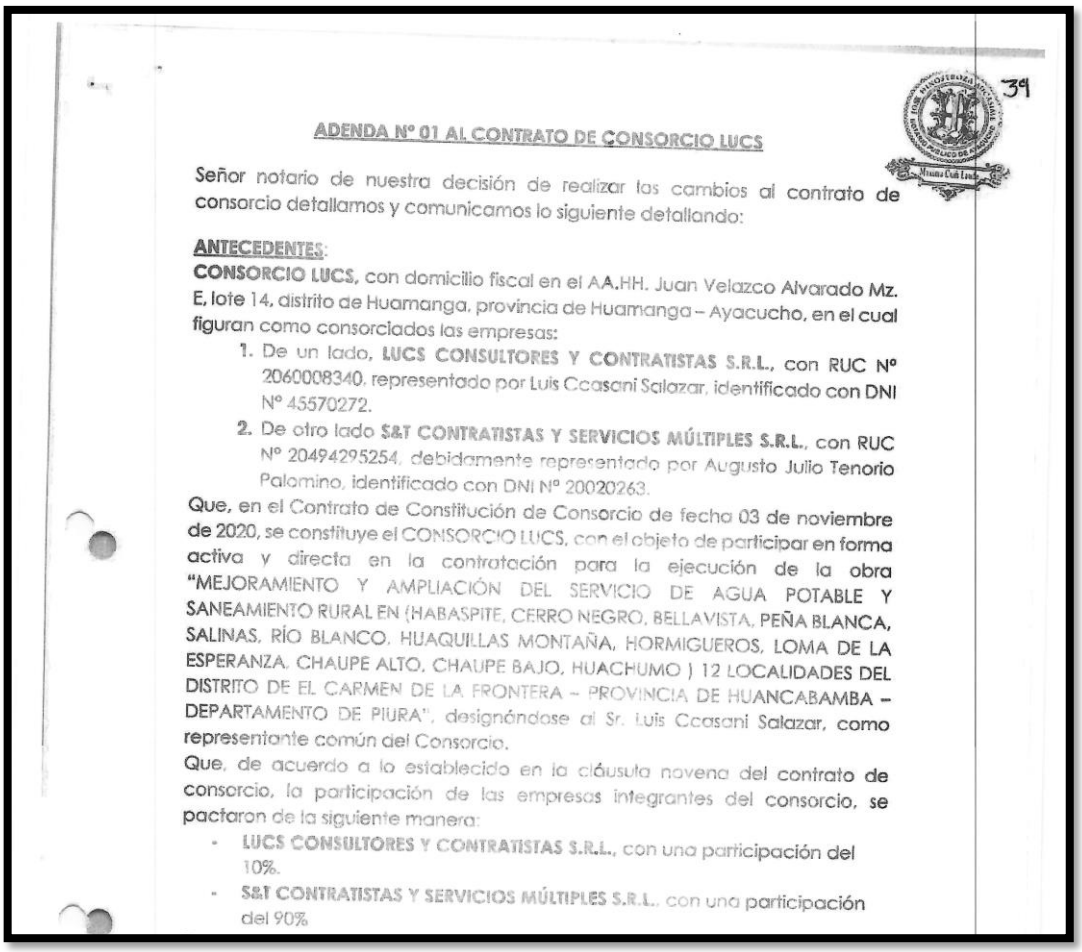
    140.1. El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes ante Notario, designándose en dicho documento al representante común. No tienen eficacia legal frente a la Entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante común.
    140.2. Las disposiciones aplicables a consorcios son establecidas mediante Directiva emitida por el OSCE. (…)

22. En atención a lo indicado, resulta necesario tener en cuenta lo señalado en las disposiciones aplicables a los Consorcios, desarrolladas en la Directiva elaborada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La Directiva N° 005-2019-OSCE/CD – Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado[4] (en adelante, la Directiva), establece en el ítem 2, del

[4] Directiva de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

numeral 7.4.2 que es posible modificar la designación del representante común del Consorcio, siempre que todos los integrantes del Consorcio suscriban el acuerdo que disponga la modificación adoptada y agrega que el referido acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha en que se notifique por vía notarial a la Entidad.

23. En ese sentido, corresponde analizar sí los documentos presentados en el proceso se enmarcan dentro de las disposiciones establecidas por el Organismo Supervisor. Por un lado, se advierte que la Adenda N° 01 al Contrato de Consorcio Lucs, fue suscrita únicamente por la empresa S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES SRL, tal como se puede advertir a continuación.



39

ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE CONSORCIO LUCS

Señor notario de nuestra decisión de realizar las cambios al contrato de consorcio detallamos y comunicamos lo siguiente detallando:

ANTECEDENTES:

CONSORCIO LUCS, con domicilio fiscal en el AA.HH. Juan Velazco Alvarado Mz. E, lote 14, distrito de Huamanga, provincia de Huamanga – Ayacucho, en el cual figuran como consorciados las empresas:

1. De un lado, **LUCS CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.R.L.**, con RUC N° 2060008340, representado por Luis Ccasani Salazar, identificado con DNI N° 45570272.
2. De otro lado **S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L.**, con RUC N° 20494295254, debidamente representado por Augusto Julio Tenorio Palomino, identificado con DNI N° 20020263.

Que, en el Contrato de Constitución de Consorcio de fecha 03 de noviembre de 2020, se constituye el CONSORCIO LUCS, con el objeto de participar en forma activa y directa en la contratación para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RÍO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE ALTO, CHAUPE BAJO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", designándose al Sr. Luis Ccasani Salazar, como representante común del Consorcio.

Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula novena del contrato de consorcio, la participación de las empresas integrantes del consorcio, se pactaron de la siguiente manera:

- **LUCS CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.R.L.**, con una participación del 10%.
- **S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L.**, con una participación del 90%

(…)

y sus modificatorias, así como para los proveedores que participen en consorcio en las contrataciones que realicen las Entidades.

38

- **Carta Notarial** N° 002 – 2024 MDCF/ALC 27 de mayo 2024 invitación de la Municipalidad de Carmen de la Frontera – Huancabamba intención de continuar con la ejecución de obra. vía Conciliación.
- Carta Notificación N° 087-2024-STCONS/G.C., de fecha 20 de junio de 2024. Diligenciada por el Sr. Augusto Tenorio Palomino
- **Carta Notarial** N° 02 – 2024 de fecha 25 de junio del 2024 diligenciada por el Notario Público José Hinostroza Aucasime.
- Carta Citación legalizada N° 04 de fecha 30 de julio del 2024, Diligenciado por el Sr Augusto Tenorio Palomino.
- Carta Citación legalizada N° 06 de fecha 01 de agosto del 2024, diligenciada por el Sr. Kelvin Wilmer Tenorio Estrada.
- **Carta Notarial** N° 07-2024, de fecha 02 de agosto del 2024 diligenciada por Notario Público Gudelia Machaca Calle.
- **Carta Notarial** N° 08-2024, de fecha 05 de agosto de 2024 diligenciada por Notaria Público Gudelia Machaca Calle.
- **Carta Notarial** N° 09-2024, de fecha 05 de agosto del 2024 diligenciado por el Notario Público José Hinostroza Aucasime

A pesar de haber sido notificado válidamente en múltiples oportunidades, el representante de la empresa **LUCS CONSULTORES Y CONTRATISTA GENERALES S.R.L. no cumplió con atender lo solicitado por nuestra parte**, por lo que, en salvaguarda de nuestros intereses y considerando el porcentaje de nuestra participación con el Consorcio LUCS es del (90%), se realizan las siguientes modificaciones:

OBJETO DE LA ADENDA N° 01

CAMBIO DE REPRESENTANTE COMÚN: Se designa como nuevo representante común del **CONSORCIO LUCS** al sr. *AUGUSTO JULIO TENORIO PALOMINO* identificado con DNI N° 20020263

CAMBIO DE OPERADOR TRIBUTARIO: Se señala que el encargado de la emisión de facturas y la contabilidad sea asumido por la empresa **S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L.,**

CAMBIO DE DOMICILIO: Se establece como nuevo domicilio en Asoc. Sector Publico Mza P LTe 14 – Ayacucho correo electrónico atenorio12@hotmail.com

Ayacucho, 08 de agosto de 2024.

S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L.
Augusto J. Tenorio Palomino
Gerente General

AUGUSTO JULIO TENORIO PALOMINO
S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L.
RUC N° 2049429525

LEGALIZACIÓN AL REVERSO

24. Asimismo, la Resolución de Alcaldía N° 0244-2024-MDCF/ALC a través de la cual se aprobó el cambio de representante común del Consorcio, tuvo en cuenta la Adenda suscrita únicamente por el consorciado S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES SRL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL RURAL Y FRONTERIZA
EL CARMEN DE LA FRONTERA – HUANCABAMBA
(Creado Por Ley 15248 Del 30 De Noviembre De 1964)

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0244-2024-MDCF/ALC.

Sapatache, 11 de setiembre del 2024.

VISTO:
El Informe Legal N° 103-2024-MDCF-UAJ-GFBS, de fecha 11 de setiembre del 2024, el Informe N° 885-2024-MDCF-DDUR-ING°LRCT/J, de fecha 13 de agosto del 2024, la Carta N° 003-2024-C-L-RC/ATP, de fecha 12 de agosto del 2024, la Adenda N° 01 al contrato de CONSORCIO LUCS, Carta Notarial N° 009-2024, Carta Notarial N° 008-2024, Carta Notarial N° 007-2024, Carta Notarial N° 006-2024, Carta Notarial N° 004-2024, Carta Notarial N° 002-2024, respecto al **CAMBIO DE REPRESENTANTE COMUN Y AUTORIZACION DE ADENDA DE CONTRATO DEL CONSORCIO LUCS,**

(…)

Que, en cuanto al cambio de representante legal y cambio de operador tributario solicitada mediante carta notarial por la empresa CONSORCIO LUCS, se ha podido evidenciar que los socios S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES con participación del 90% quienes conformarían el CONSORCIO LUCS han venido realizando la notificación correspondiente mediante carta notariales, al ING. LUIS CCASANI SALAZAR con la finalidad de realizar el cambio de representante legal ya que como socios se han visto perjudicados con la representación del señor LUIS CCASANI SALAZAR al no tener interés de dar la continuidad en la ejecución de obra, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE ALTO, CHAUPE BAJO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA. Asimismo, señalan que el señor LUIS CCASANI SALAZAR se encontraría como NO HABIDO, viéndose en la obligación los socios perjudicados en convocar a una ASAMBLEA GENERAL de socios, con el único fin de REVOCAR AL REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO LUCS. Al señor LUIS CCASANI SALAZAR,

Que, mediante Acta de Asamblea General de fecha 06 de agosto del 2024 con participación del 100% de la empresa S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L. quien tiene una participación del 90% en CONSORCIO LUCS tomaron el siguiente acuerdo por UNANIMIDAD: 1) Revocar al Representante Común del Consorcio Lucs. Al señor LUIS CCASANI SALAZAR identificado con DNI N° 45570272 de forma UNILATERAL y realizar el cambio de representante Común al señor AUGUSTO JULIO TENORIO PALOMINO identificado con DNI N° 20020263, quien representa a la empresa S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L. quienes cuentan con la participación del 90% en CONSORCIO LUCS. Que, el Sub numeral 2 del numeral 7.4.2. de la directiva N° 005-2019-OSCE-CD respecto a la modificación del contenido, párrafo segundo establece: para modificar la información contenida en los literales B) referida a la designación de representante común del consorcio y C) referido al domicilio común del consorcio del numeral precedente, todos los integrantes del consorcio deben

25. Los documentos exhibidos, permiten advertir que el cambio de representante común del Consorcio, fue realizado sólo por una de las partes que conformaron y suscribieron el contrato de Consorcio el 03 de noviembre de 2020, situación que no

se ajusta a la exigencia establecida en la Directiva de Consorcio aprobada por el OSCE, aplicable al presente caso.

26. Por tal motivo, se concluye que el cambio de representante común del CONSORCIO LUCS, no siguió las formalidades exigidas en la Directiva de Consorcio, que son las siguientes: **(i) que** todos los integrantes del Consorcio suscriban el acuerdo que disponga la modificación adoptada y, **(ii) que** el referido acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha en que se notifique por vía notarial a la Entidad, por lo que, en el presente caso no puede considerarse que el cambio de representante común del Consorcio se haya materializado.

27. Cabe agregar que la calidad de representante común del señor Cassani, obra también en el Acta de Conciliación suscrita por ambas partes de fecha 29 de agosto del presente año.

28. Asimismo, en relación a lo señalado por la Entidad respecto a lo dispuesto en la Opinión N° N° 094-2019/DTN del 10 de junio de 2019, esta se refiere a la cesión de derechos de cobro y garantías a favor de un tercero, pero no desarrolla las formalidades que se debe seguir para modificar la designación del representante común del Consorcio, procedimiento que sí se encuentra contemplado en la Directiva.

29. En tal sentido, a efectos del análisis del presente caso, no existe documentación en el proceso que permita advertir que luego de suscrito el Contrato de Consorcio el 03 de noviembre de 2020, ambos Consorciados hayan comunicado a la Entidad el cambio de designación del representante común. En tal sentido, quién presentó la solicitud de arbitraje de emergencia, Sr. Luis Cassani Salazar, es quien a la fecha tiene la calidad de representante común del Consorcio. en consecuencia, cuenta con facultades para la presentación de la solicitud cautelar.

<u>De los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud de emergencia</u>

30. Conforme se indicó en el numeral 9 de la presente resolución, las prerrogativas del árbitro de emergencia tienen como parámetros los límites que la norma adjetiva y sustantiva imponen en cuanto al otorgamiento de la tutela cautelar.

31. En ese sentido, corresponde tener en cuenta que la solicitud cautelar deriva de un conflicto que se ha originado con motivo de la suscripción del Contrato N° 22-2020-MDCF suscrito el 25 de noviembre del 2020 entre el Consorcio LUCS y la Municipalidad Distrital de El Carmen de La Frontera para la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO, CHAUPE ALTO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES, DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2462126.

32. Teniendo en cuenta el objeto contractual, corresponde observar lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 206-2024-EF[5] – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, que indica lo siguiente, con respecto a las medidas cautelares[6]:

> ***"Tercera. Medidas cautelares***
> *Las medidas cautelares que se presentan respecto de los contratos de ejecución de obras públicas, tanto en la vía judicial como en la arbitral, se rigen por las siguientes reglas de admisibilidad y procedibilidad:*
> *1. El juez competente es el especializado en lo comercial o en su defecto en lo civil del domicilio principal de la entidad convocante o contratante. Constituye causal de nulidad las medidas cautelares otorgadas por la autoridad judicial inobservando el presente numeral.*
> *2. La interposición de una medida cautelar requiere la presentación de una contracautela, la que se acredita únicamente con la presentación de una fianza bancaria la cual debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en favor de la entidad convocante o contratante, bajo responsabilidad de las empresas que la emiten, con una vigencia no menor de 6 (seis) meses, debiendo ser renovada por el tiempo del proceso judicial o arbitral. Constituye causal de improcedencia de la medida cautelar cuando se presente una caución juratoria como contracautela.*
> *El monto de la contracautela lo establece el juez, el tribunal arbitral o árbitro único ante quien se solicita la medida cautelar. Dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento presentada para la suscripción del contrato. Si el monto de la solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel cumplimiento, el monto de la contracautela es equivalente al monto protegido por la medida cautelar.*
> *Las empresas que emiten la fianza bancaria deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), contar con clasificación de riesgo B o superior y estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.*
> *El juez, tribunal arbitral o árbitro único, según corresponda, que reciba la solicitud cautelar verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de recibir la fianza bancaria, constituyendo causal de nulidad de la medida cautelar en caso de que esta se conceda con inobservancia de tales requisitos.*

---

[5] Publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de noviembre de 2024.

[6] Al respecto, corresponde tener en cuenta que si bien el Decreto Supremo N° 206-2024-EF tiene como objeto establecer el marco legal que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Debe tenerse en cuenta que, en el desarrollo del precepto normativo, se advierte claramente la distinción de "obra pública paralizada" y "obra pública". En tal sentido, corresponde precisar que la tercera disposición complementaria final, no delimita las reglas de admisibilidad y procedibilidad a las obras públicas paralizadas, su redacción está enfocada en medidas cautelares respecto a contratos de ejecución de obras públicas, como lo es en el presente caso. Asimismo, se debe considerar adicionalmente que el Decreto de Urgencia N° 20-2020 aplicable a los contratos en el que estado sea parte, ha dispuesto también la presentación de garantías que garantiza la medida cautelar que se pretenda.

3. Presentada la solicitud cautelar, se verifican los requisitos de admisibilidad y procedibilidad. El plazo para subsanar errores materiales u omisiones en la presentación de los requisitos es de 5 (cinco) días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada las observaciones. Verificado el cumplimiento de requisitos dentro del plazo otorgado, se dispone la continuación del trámite; caso contrario, se rechaza la solicitud.
4. El juez, tribunal arbitral o árbitro único, según corresponda, corre traslado de la solicitud a la contraparte, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su presentación o de la subsanación de errores u omisiones, según corresponda, y otorga un plazo de 5 (cinco) días hábiles para que exprese por escrito lo conveniente a su derecho. Con o sin la absolución, se resuelve la solicitud dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para la absolución.
5. No es procedente la concesión de una medida cautelar sin traslado previo a la contraparte.
Previa a su decisión, el juez, tribunal arbitral o árbitro único deben evaluar la irreversibilidad de la medida, así como el perjuicio que de esta se derive contra el interés público.
(…)"

33. En virtud de lo expuesto, se advierte que la normativa aplicable exige el cumplimiento estricto de los requisitos para la admisibilidad y procedibilidad de la solicitud cautelar, entre los cuales se indica que constituye causal de improcedencia de la medida cautelar cuando se presente una caución juratoria como contracautela. Al respecto, se advierte que el CONSORCIO LUCS, en el numeral 10 de su solicitud cautelar, ofreció como contracautela una caución juratoria, por el monto que indique el árbitro de emergencia, lo cual no puede ser amparado por esta Árbitro de Emergencia.

34. En razón a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 206-2024-EF, se concede el plazo de cinco (05) días hábiles al Consorcio LUCS para que acredite la presentación de una contracautela a favor de la Entidad, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, en la forma de una fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, conforme a lo dispuesto en el referido Decreto. .

35. Cabe precisar que el monto de la contracautela, se determinó teniendo en cuenta que la norma establece que el mismo no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento presentada para la suscripción del contrato y, atendiendo a que la pretensión cautelar formulada por el CONSORCIO LUCS fue la siguiente:

> **3. PRETENSIÓN CAUTELAR:**
>
> En amparo de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento Arbitraje del Centro de Arbitraje – CECARD y el artículo 47 del Decreto Legislativo Nro. 1071 Ley de Arbitraje; SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN:
>
> - ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, SE ABSTENGA A EJECUTAR la garantía de Fiel Cumplimiento, otorgado por nuestra representada mediante CARTA FIANZA N° 1017008-2024/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles).

36. El plazo para subsanar la presentación de los requisitos es de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud cautelar. Una vez subsanado el requisito de procedibilidad establecido en el Decreto Supremo N° 206-2024-EF, este Árbitro de Emergencia emitirá su decisión respecto al pedido cautelar formulado por Consorcio Lucs.

37. Finalmente, se deja constancia que en cumplimiento de lo establecido en la Ley N°31589 y su Reglamento, a través de la Resolución N° 02 se corrió traslado a la Entidad de todos los actuados del proceso a efectos que ejerza oportunamente su derecho de defensa, sin restricción alguna.

<u>Respecto a la vigencia de la Resolución N° 01, cuestionada por la Entidad</u>

38. De acuerdo a la evaluación de admisión y procedencia de la solicitud cautelar presentada por el representante común de CONSORCIO LUCS, se advierte del contenido de la Resolución N° 01 recaída en el presente proceso de emergencia, que esta no consideró los requisitos de procedibilidad y admisibilidad contenidos en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 206-2024-EF, por lo tanto, teniendo en cuenta que se ha brindado a Consorcio Lucs el plazo de cinco (5) días hábiles para que subsane el requisito de presentación de la garantía, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 01, debiendo notificar esta decisión a las partes y la empresa FOGAPI, tercero a quién se le notificó al inicio del presente proceso de emergencia.

Finalmente, mediante razón de secretaría arbitral de vistos vi) comunicó que Consorcio Lucs cumplió acreditar los gastos arbitrales del presente proceso, lo que corresponde tener presente y por cumplido dentro del plazo otorgado por la secretaría para su acreditación.

Por lo que, estando a lo expuesto, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:**

<u>Primero:</u> TENER POR CUMPLIDO el requerimiento dispuesto por la Árbitro de Emergencia en la Audiencia Especial por parte de la Procuraduría Publica de Huancabamba, mediante la Carta de vistos **iv),** con conocimiento de su contraparte.

<u>Segundo</u>: DEJAR CONSTANCIA que el CONSORCIO LUCS no cumplió con el requerimiento dispuesto por la Árbitro de Emergencia en la Audiencia Especial, con conocimiento de su contraparte.

<u>Tercero:</u> DECLARAR que la solicitud cautelar en el presente proceso de emergencia fue presentada por el representante común del CONSORCIO LUCS, Sr. Luis Ccasani Salazar.

<u>Cuarto:</u> OTORGAR al CONSORCIO LUCS el plazo de cinco (05) días hábiles para que acredite la presentación de una contracautela a favor de la Entidad, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, en la forma de una fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud cautelar.

<u>Quinto:</u> DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 01 de fecha 26 de noviembre de 2024 emitida por el Abogado Álvarez Solís, en virtud a los considerados expuestos en la presente Resolución y, **NOTIFICAR** la presente Resolución a las partes y adicionalmente a la empresa FOGAPI para conocimiento y fines pertinentes.

<u>Sexto:</u> DISPONER que la secretaria Arbitral notifique las partes la presente resolución y los documentos de vistos a las partes y tercero.

La presente Resolución fue elaborada por el Árbitro de Emergencia, Abogada Ana Cristina Velásquez De La Cruz.

ANA CRISTINA VELÁSQUEZ DE LA CRUZ

ANA CRISTINA VELÁSQUEZ DE LA CRUZ
Árbitro de Emergencia

Resolución N° 06
Lima, 07 de enero de 2025

VISTOS:

- **i)** Resolución N° 05 de fecha 23 de diciembre de 2024 en la misma fecha a las partes.
- **ii)** Escrito con sumilla *"Solicito ampliación de plazo",* presentado el 02 de enero de 2025 por el Consorcio Lucs (en adelante, el Consorcio).

CONSIDERANDO:

1. Mediante la Resolución de vistos **i)**, debidamente notificada a las partes el 26 de diciembre de 2024, se resolvió, entre otros, lo siguiente:

   "(…)

   Segundo: ***DECLARAR INFUNDADA*** *la reconsideración presentada por Consorcio Lucs contra el cuarto y quinto resolutivo de la Resolución N° 03, por lo tanto, la referida Resolución, en su integridad, surte efectos.*

   Tercero: ***REACTIVAR*** *el plazo otorgado a CONSORCIO LUCS para que acredite la presentación de una contracautela a favor de la Entidad, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, en la forma de una fianza bancaria incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud cautelar.*

   Cuarto: ***PRECISAR*** *que el plazo otorgado a CONSORCIO LUCS dispuesto en la Resolución N° 03 se reactiva sólo respecto de los días pendientes (04 días hábiles[1]), contado a partir del día siguiente de su notificación[2].*

2. Mediante el escrito de vistos **ii),** el Consorcio solicitó una ampliación de plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo dispuesto en la Resolución N° 05, fundamentando su pedido en los siguientes argumentos:

   - A consecuencia de la ejecución de la carta fianza presentada a la Municipalidad como garantía de fiel cumplimiento, las entidades financieras están negando la emisión de una nueva garantía, exigiendo como condición el abono del 100% del monto de la garantía, además del pago de comisiones asociadas a dicho concepto.
   - El Consorcio carece de la liquidez necesaria para realizar el depósito exigido por la entidad financiera, debido a que, previo a la resolución contractual,

---

[1] Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD
(…)
Artículo 28º.- Plazos
1. Los plazos dispuestos por el Reglamento se comenzarán a computar desde el día siguiente de la notificación física o la notificación realizada por correo electrónico.
2. Las notificaciones realizadas por correo electrónico no requieren acuse de recibido, siendo responsabilidad de las partes verificar que los correos electrónicos proporcionados como domicilios procesales se encuentren habilitados y configurados para recibir las comunicaciones y notificaciones.
3. Los plazos se computan por días hábiles. Se consideran días inhábiles los días sábados, domingos, feriados no laborables y **los días que se decreten como no laborables para la administración pública**, incluidos los feriados y días no laborales locales o regionales que afecten a una de las partes, así como los días de duelo nacional no laborales declarados por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Arbitral, en consulta con las partes, puede establecer un cómputo de plazos por días calendario. (…)

[2] Resolución enviada a la secretaría por el Árbitro Emergencia el lunes 23 de diciembre de 2024 (día no laborable para la administración pública), por lo que se debe tener por notificada el primer día hábil siguiente (26 de diciembre de 2024). El plazo de 4 días hábiles venció el viernes 03 de enero de 2025.

asumió los costos de ejecución de la obra mientras la Entidad mantiene pendiente el pago de valorizaciones y mayores metrados ejecutados durante la vigencia del contrato.

- La ejecución de la carta fianza y el incumplimiento de pago por parte de la Entidad han generado dificultades adicionales para que el Consorcio cumpla con la presentación de la nueva garantía en el plazo establecido.
- Además, señaló que las festividades navideñas y de fin de año ocasionaron demoras en la atención oportuna por parte de las instituciones financieras.
- No obstante, el Consorcio indicó que se encuentra gestionando un préstamo dinerario con el objetivo de cumplir con el depósito solicitado por la entidad financiera, señalando que esta gestión tomará algunos días adicionales para su aprobación.

3. De la revisión de la solicitud formulada por el Consorcio, se advierte que está fue presentada un día antes del vencimiento del plazo otorgado, por lo que corresponde emitir pronunciamiento. Asimismo, teniendo en cuenta que la solicitud de ampliación de plazo se sustenta en hechos conocidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 8 del Anexo I-Reglamento de Emergencia del Centro, se emitirá pronunciamiento sin traslado a la Entidad.

4. Así, el Consorcio solicita que acceda a su pedido de ampliación de plazo por quince (15) días hábiles adicionales para la presentación de la contracautela.

5. Para analizar el pedido formulado por el Consorcio corresponde recordar que el marco normativo aplicable es la Tercera Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N° 31589 y el numeral 2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1071-Ley de Arbitraje. Ambas disposiciones disponen la necesidad de observar estrictamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para el otorgamiento de medidas cautelares en contratos de obra donde el Estado sea parte, así como la debida observancia de los plazos establecidos para la susbsanación requerida.

6. En efecto, el numeral 3 del TUO de la Ley N° 31589 dispone que: *"(...) Verificado el cumplimiento de requisitos dentro del plazo otorgado, se dispone la continuación del trámite; caso contrario, se rechaza la solicitud"*.

7. En concordancia con lo anterior, la normativa aplicable al caso en concreto dispuso un plazo de cinco (5) días hábiles para que se subsane cualquier requisito de admisibilidad y procedibilidad del pedido de medida cautelar. Asimismo, se advierte que esta norma no contempla ni habilita la posibilidad de otorgar plazos adicionales al establecido (5 días hábiles) para subsanar "omisiones" o falta de requisitos, en el presente caso la omisión de la presentación de la contracautela.

8. Por otro lado, corresponde destacar que el presente arbitraje de emergencia se ha resguardado y garantizado el debido proceso a ambas partes en igualdad de condiciones desde que la suscrita asumió competencia, como se aprecia a continuación:

Evento	Plazo otorgado	Observación

Plazo otorgado al Consorcio para presentar su contracautela (Resolución N° 03) de fecha **12 de diciembre de 2024.**	05 días hábiles	Consorcio presentó recurso de reconsideración.
Suspensión de lo dispuesto en el cuarto y quinto punto resolutivo de la Resolución N° 3	—	Durante la evaluación, traslado y decisión respecto a la reconsideración, se suspendió el plazo otorgado para la subsanación de la contracautela.
Plazo concedido a la Entidad para absolver la reconsideración planteada por el Consorcio (Resolución N° 04)	2 días hábiles	La Entidad presentó absolución dentro del plazo otorgado.
Resolución que declara infundada la reconsideración planteada por el Consorcio (Resolución N° 05) **del 23 de diciembre de 2024**	2 días hábiles Reactivación del plazo pendiente por **4 días hábiles**	Se reactivó el plazo otorgado al Consorcio para la presentación de su contracautela. **El nuevo plazo venció el 03 de enero de 2025**

9. Conforme se advierte, el Consorcio contó con un plazo mayor a los 5 días hábiles otorgados para realizar las gestiones necesarias e iniciar los trámites que le permitan obtener la presentación de la contracautela. Ello sin considerar los días generados desde la presentación de la solicitud de emergencia el 26 de noviembre de 2024.

10. En consecuencia, el Consorcio es responsable de adoptar oportunamente las acciones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos en la Tercera Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N.º 31589 y del numeral 2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1071 - Ley de Arbitraje[3], normas que establecen de manera imperativa los requisitos para la procedencia de medidas cautelares.

11. Asimismo, estamos ante un arbitraje de derecho y el principio de legalidad exige el cumplimiento estricto de la Ley. En razón a lo indicado corresponde declarar No ha lugar la solicitud del Consorcio y por ende no corresponde otorgarle un plazo adicional de quince (15) días hábiles para que cumpla con presentar el requisito de admisibilidad y procedibilidad, contracautela.

[3] Normas que establecen de manera expresa y obligatoria que, en el caso de contratos de obra donde el Estado peruano es la parte afectada por una medida cautelar, la procedencia de dicha medida está condicionada a la presentación de una contracautela en forma de fianza bancaria.

12. Por otro lado, el viernes 03 de enero de 2025 venció el plazo otorgado al Consorcio para que cumpla con subsanar el requisito de admisibilidad y procedibilidad exigido, contracautela, dentro del plazo establecido en el numeral 3 del artículo 9 del Anexo I- Reglas de Arbitraje de Emergencia del Centro, corresponde, de conformidad con el numeral 3 de la Tercera Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N° 31589, rechazar la solicitud cautelar formulada por Consorcio Lucs el 26 de noviembre de 2024.

Por lo que, estando a lo expuesto, el Árbitro de Emergencia **RESUELVE:**

Primero: **TENER PRESENTE** el escrito de vistos **ii)** presentado por Consorcio Lucs**,** con conocimiento de la Entidad.

Segundo: **RECHAZAR** la solicitud de ampliación de plazo de 15 días hábiles, formulado por el Consorcio Lucs, para la presentación de su contracautela.

Tercero: **DECLARAR** que el plazo otorgado al Consorcio para la presentación del requisito de admisiblidad y procedibilidad, contracautela, venció el viernes 03 de enero de 2025.

Cuarto: **RECHAZAR** la solicitud cautelar de fecha 26 de noviembre de 2024 formulada por el Consorcio Lucs, de conformidad con los considerando expuestos en la presente Resolución.

La presente Resolución fue elaborada por el Árbitro de Emergencia, Abogada Ana Cristina Velásquez De La Cruz.

ANA CRISTINA VELÁSQUEZ DE LA CRUZ

ANA CRISTINA VELÁSQUEZ DE LA CRUZ
Árbitro de Emergencia